



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 96/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

התובעים: 1. בצלאל שמחוביץ ת.ז. 20853
2. אסתר שמחוביץ ת.ז. 91579
ע"י ב"כ עו"ד יהושע נגר
מרחוב יפו 33 ירושלים

נ ג ד

הנתבעים: 1. רוברט הנוך ת.ז. 332336957
2. מונה הנוך ת.ז. 332289081
ע"י ב"כ עוה"ד עודד הכהן
מרחוב שלומציון המלכה 18 ירושלים

ה ח ל ט ה

הצדדים להליך דנן הינם בעלי דירות בבית המשותף ברחוב הצפירה 1 ירושלים הבנוי על חלקה 80 בגוש 30010 (להלן: "הבית").

במסגרת ההליך מבקשים התובעים כי הנתבעים, אשר תפסו חזקה ייחודית בגג הבית, יחוייבו לסלק את ידם מכל חלקי הרכוש המשותף ולפרק/להרוס כל בניה שבוצע על ידם ברכוש המשותף, כי הנתבעים יחוייבו לאפשר לתובעים גישה חופשית לגג הבית וכי יוסר צינור ביוב וצנרת נוספת שהותקנה על ידי הנתבעים בחזית הבית.

במסגרת כתב ההגנה טענו הנתבעים כי יש לסלק את התובענה על הסף מאחר והוגשה בקשה לצו מניעה זמני בבית משפט השלום בירושלים שעילתה זהה, ואת בקשתם זו מחקו התובעים לאחר ש"הבינו" את עמדתה של השופטת היושבת בדין, המדובר בתובענה שאינה אלא ניצול לרעה של הליכי משפט וניסיון ל"אתר" מותב רביעי אשר ישהה לטענות התובעים וכי העילות שעניינן בניית החדר על הגג והעליה במדרגות לגג נדונו והוכרעו בפסקי דין של בית משפט השלום והמחוזי.

ביום 15.11.11 נערך דיון בתובענה ובסיומו קבעתי כי "בטרם ניתן לקבוע את התיק להמשך, יש לדון תחילה בטענה כי עילת התביעה שעניינה סילוק והריסה מגג הבית נדונה כבר בהליכים קודמים". לפיכך הוריתי לצדדים לסכם את טענותיהם בכתב וכך הם עשו.

דיון

בע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ – משכן נ' לאה נגר (פורסם בנבו) מסכמת כבוד השופטת חיות את ההלכות בנוגע לכלל בדבר מעשה בית דין:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 96/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

"הכלל בדבר מעשה בית דין משמעו כי צדדים להליך מנועים מלחזור ולהתדיין ביניהם בבתי המשפט בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. בבסיס הכלל עומדים טעמים שבטובת הציבור שעיקרם הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו. כמו כן מיועד הכלל של מעשה בית-דין להגן על האינטרסים של בעלי הדין ולמנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין (ראו: משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי - הלכה ומעשה 666 (כרך א', 2007) (להלן: קשת); ע"א 3097/02 מלמד נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, פ"ד נח(5) 511, 519 (2004); ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 (לא פורסם, [פורסם בנבו], 8.9.2005) (להלן: עניין גורה); מיכאל בן-יאיר "הרחבת תחולתו של מעשה בית דין על מי שלא היה צד להליך קודם" ספר יצחק כהן 302 (1989)). הדוקטרינה של מעשה בית דין נחלקת לשני ראשים.

הראש האחד עניינו בהשתק עילה ולפיו פסק דין סופי שניתן לגופו של עניין מעניק לנתבע (או לחליפו) חסינות מפני תביעה נוספת של התובע (או חליפו) בגין אותה עילת תביעה. בהקשר זה ניתנה למושג "עילת תביעה" משמעות רחבה במטרה להגשים את תכלית הכלל ולמנוע את הטרדת הנתבע בתביעות חוזרות בשל אותו מעשה (ראו: ע"א 303/79 אבני נ' גליקסמן, פ"ד לה(1) 92, 98 (1980); ע"א 8/83 גורדון נ' כפר מונאש - מושב עובדים, פ"ד לח(4) 797, 801 (1985); רע"א 6498/05 צבעוני נ' בנק הפועלים בע"מ - סניף עפולה עלית (לא פורסם, [פורסם בנבו], 23.2.2006)).

הראש השני הוא השתק פלוגתה, ולפיו כאשר פלוגתה, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים, הוכרעה באופן פוזיטיבי בפסק דין סופי (במפורש או מכללא), ההכרעה היתה חיונית לתוצאה הסופית ולבעלי הדין "היה יומם" ביחס לאותה פלוגתה, יהיו בעלי הדין (או חליפיהם) משותקים מלהתדיין לגביה שוב (ראו: נינה זלצמן מעשה בית-דין בהליך אזרחי, 3-4, 29, 137-141 (1991) (להלן: זלצמן); ע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 561, 583-585; עניין גורה, פסקה 7). יודגש כי כאשר הפלוגתה היא בשאלה מעורבת של חוק ועובדה כלל ההשתק חל הן על הממצאים העובדתיים והן על המסקנה המשפטית הנגזרת מהם (ראו זלצמן, 164. אך ראו הסייגים לכלל במשפט הפלילי ובמשפט האזרחי: ע"פ 447/88 לוונטהל נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(2) 1, 6 (1990); ע"א 1418/90 מאור נ' הרשנהורן, פ"ד מה(3) 95, 102-105 (1991); ע"א 1351/06 עו"ד ח'ורי נ' חברת ארמון ההגמון (קסר אלמוטראן) בע"מ, פסקאות ל"א(2)-ל"ו (לא פורסם, [פורסם בנבו], 17.9.2007); ע"א 5610/93 זלסקי נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ראשון לציון, פ"ד נא(1) 68, 98-100 (1997). ולחסרונותיו של הכלל ראו רע"א 682/07 לבייב נ' גילד, פסקה יא' (לא פורסם, [פורסם בנבו], 20.6.2007); אליהו הרנון "הפלוגתה הפסוקה (Collateral Estoppel) כמעשה בית-דין" הפרקליט כג 344, 352-353 (1967)).

בדיון מיום 15.11.11 הבהיר ב"כ התובעים את טענות מרשיו לעניין הגג "היו סכסוכים בין משפ' גיל שקדמה למשיבים כאן, שהם לא אנשים תמימים והם עורכי דין, ההליכים שם לא נגעו כהוא זה לעבודות נשוא ההליך כאן, לגבי צינור הביוב. לגבי הגג יש לנו טענה של בנייה שעדיין קיימת במקום, ללא היתר, לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 96/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

מהווה חלק מהבית המשותף כל עוד לא הוכשרה ולא נרשמה כדין, אותו הליך כפי שהסתיים שם לא סגר בפנינו את הדלת לעלות טענות שהיום אנו מעלים, שהם לא היו שם. הגג הוא לא רכוש צמוד, אף אם היה רכוש צמוד זה לא מתיר בנייה תוך שימוש באחוזי בניה ששייכים לכלל הדיירים ולא לבניה ללא היתר, הגג שמעל הבנייה צריך להיות רכוש משותף באמצעות גישה מסודרת, באמצעות מדרגות, והגישה היחידה היא מהבית שלהם והם לא מאפשרים כניסה אליו. כיום הטענה היא שהם היום עושים שימוש ייחודי בגג שמעל התוספת שהם בנו, שגם היא לא חוקית, ולא נותנים גישה לשם. כיון שאני לא יכול להיכנס לשם, אני גם לא יכול לצלם" (עמוד 2 לפרוטוקול מיום 15.11.11 שורות 6-10) (ההדגשות שלי, א.ס.).

יוצא אם כן כי טענות התובעים לעניין הגג הינן בנוגע לחסימת הגישה לגג העליון שמעל לתוספת הבניה. טענותיהם לגבי הבניה בפועל על הגג היא כי הבניה "עדיין קיימת במקום" (על הגג), היא לא הוכשרה ולא נרשמה כדין ונעשה שימוש באחוזי בניה המהווים רכוש משותף. אין כל טענה כי בוצע על ידי הנתבעים בינוי נוסף או אחר על גג הבית.

אין מחלוקת כי בין התובעים דנן לבין הקודמים לנתבעים בזכויות התנהל הליך קודם בבית משפט השלום בירושלים בתיק 14565/06 בפני כבוד השופט מינץ. אין גם מחלוקת כי הליך זה נסתיים בפסק דין מיום 23.11.08 במסגרתו נדחתה תביעת התובעים דנן לפיה סופחו לטובת דירת הנתבעים שטח גג לטובת בניית חדר נוסף וגרם מדרגות המוביל אל אותה קומה נוספת (נספח 3/ נכתב ההגנה) (להלן: "פסק הדין בשלום"). במסגרת פסק הדין נדונו גם טענות התובעים בנוגע לצנרת חיצונית שהותקנה.

אין מחלוקת שגם ערעור אשר הוגש על פסק דין זה בתיק ע"א 3016/09 נדחה בהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 19.03.09 (נספח 4/ נכתב ההגנה) (להלן: "פסק הדין במחוזי").

למקרא פסקי הדין הנ"ל ויישום ההלכות המצוטטות לעיל, אין מנוס מן המסקנה כי הסוגיה שעניינה בתפיסת חזקה בגג הבית ובניה על גג הבית (סעיף 17 לכתב התביעה) כבר נדונה והוכרעה ונתקיים לגביה מעשה בית דין מסוג השחק עילה.

בפסק הדין המחוזי דוחה בית המשפט את ערעור התובעים דנן על פסק הדין בשלום וקובע כי הבניה נעשתה על פי הסכמת התובעים דנן:

"לאחר ששקלנו את טענות הצדדים הגענו לכלל מסקנה לפיה דין הערעור להידחות. הטעם המרכזי שביסוד החלטתנו הוא הממצא החד משמעי המצוי בפסק הדין, לפיו התובעים הסכימו לבניית החד הנוסף. ממצא זה מעוגן בחומר הראיות שעמד לנגד עיני בית המשפט. בית המשפט האמין ללא סייג לגרסת עדי המשיבים לפיה "התובעים כולם נתנו את הסכמתם לבנייה" (סעיף 8 לפסק הדין). בכלל זה ציין בית המשפט את עדותו של מר רמי כהן, שאמו היא בעלת זכויות באחת הדירות בבניין. מעבר לאמון שנתן בית המשפט בעדויות מטעם המשיבים, מבוססת המסקנה האמורה גם על נתונים נוספים... אנו סבורים כי די היה בממצא החד משמעי אליו הגיע בית המשפט, בדבר הסכמת התובעים לבניית החד הנוסף, על אף שהסכמה זו לא עוגנה בהסכם הכתוב, כדי לבסס עליו את דחיית התובענה. מדובר בממצא בדבר הסכמה פוזיטיבית, שאינה נלמדת רק מהעדר מחאה (עניין המחזק, כשלעצמו, את המסקנה בדבר קיום ההסכמה). מעבר לכך, גם אם היה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 96/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

מדובר בהסכמה שקיומה מבוסס אך על שתיקת התובעים, הרי שבנסיבות המקרה דנן, היה מקום לקבוע שאין התובעים זכאים לסעד שהתבקש על ידם בכל הנוגע להשבת המצב לקדמותו, כפי שהוסבר בהרחבה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, בע"א 1677/05 נאווה כרמל נ' ראול ינקוביצי (פסק דין מיום 12.8.2007). בקשת רשות ערעור על פסק דין זה נדחתה על ידי בית המשפט העליון (רע"א 8186/07 נאווה כרמל נ' ראול ינקוביצי (החלטת כב' השופטת ע' ארבל מיום 1.1.08)) (סעיפים 4 ו-5 לפסק הדין).

לאור האמור בפסקי הדין הנ"ל הסכמה זו מתייחסת הן לשימוש בגג, הן לבינוי עליו והן לזכויות הבניה הנדרשות לשם כך (ר' גם סעיף 12 לפסק הדין בשלום).

הנתבעים הינם חליפיהם של הנתבעים בהליכים הקודמים המפורטים לעיל. למעשה, התובעים אינם חולקים על כך.

התובעים לא טוענים כי בוצעה בניה נוספת או חדשה בגג הבית - כך לא בדיון בפני מיום 15.11.11 כאמור לעיל וכך גם לא במסגרת סיכום הטענות מטעמם מיום 12.12.11. טענת התובעים היא כי תביעתם מתייחסת **"לבנייה חדשה ששינתה את המבנה הפנימי של המבנה הבלתי חוקי לרבות ביטול המדרגות שהובילו לגג, ובכך חסמו הנתבעים את הגישה לגג"** (סעיף 1.3. לסיוכומים, ההדגשה במקור). אין כל אזכור וכל טענה לבינוי חדש על הגג.

משכך, על פניה, כל תביעתם לסילוק יד והריסת הבנוי על גג הבית קשורה לבניה הקודמת אשר בוצעה.

זאת ועוד. כל טענות התובעים בסיכומיהם מתייחסות לחסימה של אפשרות הגישה לגג. אולם, בין כך לבין הריסה של הבנוי, לאחר שסוגיה זו נדונה והוכרעה בפני שתי ערכאות כאמור לעיל, המרחק רב.

בנסיבות אלו קם מעשה בי-דין מסוג השתק עילה בכל הנוגע להריסת הבנוי על הגג וסילוק היד הימנו (הסעד הנתבע בסעיף 17 לכתב התביעה).

בכל הקשור לפתח היציאה לגג (הסעד הנתבע בסעיף 18 לכתב התביעה) הרי שטענת התובעים היא כי המדובר בעבודות חדשות אשר בוצעו על ידי הנתבעים לאחר מתן פסקי הדין הנ"ל (ר' סעיף 1.3. ואילך לסיוכומיהם). טענות אלו מחייבות בירור עובדתי בטרם מתן הכרעה לגביהן. אולם, ברור כי, ככל שיעלה בידי התובעים להוכיח את האמור, הרי שלא יכול להתקיים מעשה בי-דין מסוג השתק עילה בנוגע לעבודות שטרם בוצעו במועד מתן פסק הדין הקודם ולפיכך כלל לא נדונו שם.

האמור נכון גם לגבי צנרת הביוב והצנרת הנוספת (הסעד הנתבע בסעיף 19 לכתב התביעה) אשר הותקנה, לטענת התובעים, בעת האחרונה, ובודאי לאחר מתן פסקי הדין הנ"ל (ר' סעיף 3.ב. לסיוכומיהם).

בהקשרים האמורים לנתבעים טענות בדבר השתק פלוגתא, הן לעניין העלייה לגג והן לעניין הצנרת החיצונית. נושאים אלו אכן נדונו במסגרת פסק הדין בשלום ואכן נקבעו ממצאים עובדתיים ומשפטיים בעניינים. כך בנוגע לעליה לגג באמצעות גרם המדרגות נפסק כי "פשיטא גם כי גרם המדרגות אינו חלק



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 96/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

מהרכוש המשותף כי אם חלק אינטגרלי מדירת הנתבעת, שכן אין מחלוקת שהוא נבנה בתוך השטח שהוצמד לדירתה והוא ככל גרם מדרגות הנועד לשמש מעבר בין שני מפלסים בדירה אחת. **אין אפוא, מקום לספק כי לתובעים אין כל זכות בגרם המדרגות שבנתה הנתבעת בתוך השטח הצמוד לדירתה.** מעבר לצריך ייאמר כי גם לו היה מוכח כי בשלב כלשהו, טרם השלימה הנתבעת את כל הבנייה, ניתן היה לעלות אל הגג באמצעות גרם המדרגות, לא היה בעובדה זו כדי להקנות זכות כלשהי לתובעים בגרם מדרגות זה" (סעיף 18 לפסק הדין). כך בנוגע לצנרת החיצונית התייחסות בפסק הדין (סעיפים 21-22 לפסק הדין).

אולם, מאחר וממילא נדרש בירור עובדתי בכל הקשור לטענות התובעים כי המדובר בצנרת חדשה וכי המדובר בעבודות חדשות אשר מנעו את הגישה לגג הבית, ומאחר ולא ניתן לדעת, בשלב זה של ההליך, האם כוונת התובעים הינה לאותו גרם מדרגות לגביו הכריע פסק הדין בשלום כאמור, ממילא, לא ניתן כעת הזו להכריע בדבר זהות הפלוגתאות או העילות, בודאי בכל הקשור לרכיביהן העובדתיים.

הנתבעים יהיו רשאים לשוב ולטעון לקיומו של מעשה בין-דין, בנושאים האמורים, במסגרת הסיכומים מטעמם לאחר גמר מסכת הראיות.

לפני סיום אעיר כי אינני מקבל, בשלב זה, את טענת הנתבעים בסיכומי התשובה (שהוגשו ללא קבלת רשות) בדבר הרחבת חזית אסורה. על פניו מבוקש בכתב התביעה סעד שעניינו במניעת הגישה לגג על ידי הנתבעים לאור בינוי שביצעו בבית. אלו הן העובדות העיקריות המהוות את עילת התביעה ואשר נדרשות בכתב התביעה בהתאם להוראת תקנה 9 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984. טענות התובעים בדבר הבינוי הפנימי הקונקרטי, חסימת הדלת וכיוצ"ב הינן הראיות לביסוס אותם עובדות עיקריות לעילת התביעה כאמור לעיל.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את הבקשה לסילוק התובענה על הסף בחלקה ומורה על דחיית התביעה, מחמת מעשה בי-דין, שעניינה בבניה על גג הבית לרבות החדר הנוסף על הגג ובתפיסת החזקה היחודית על שטח הגג לשם כך, כמפורט בסעיף 17 לכתב התביעה.

למען הסר ספק, בכל הקשור לטענה בדבר העדר הגישה לגג הבית והעבודות שבוצעו על ידי הנתבעים בהקשר זה ובכל הקשור לצנרת הביוב והצנרת הנוספת על קירות הבית, אינני מוצא מקום לדחות את התובענה בשלב זה ויש לקיים דיון לגביה.

הנתבעים יהיו רשאים לשוב ולהעלות טענותם בדבר מעשה בי דין במסגרת סיכומיהם לאחר גמר מסכת הראיות.

התובעים ישלמו לנתבעים בגין החזר הוצאות הבקשה סך של 1,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 96/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

לשם קידום הדיון בתובענה אני מורה כלהלן:

1. אני קובע מועד לביקור במקום ליום 20.12.11 שעה 13:30.
2. התובעים יגישו תצהירי עדות ראשית, לרבות חוות דעת מומחים, בתוך 30 יום ממועד הביקור במקום עם העתק ישירות לצד שכנגד.
3. הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית, לרבות חוות דעת מומחים, בתוך 30 יום נוספים עם העתק ישירות לצד שכנגד.
4. לתצהירי הצדדים יצורפו כל המסמכים שבדעת הצדדים להגיש באמצעות המצהירים. מסמכים כנ"ל יחשבו כקבלים על תנאי, אלא אם תבוא התנגדות בכתב של הצד שכנגד להגשת מסמך כאמור, אשר תוגש בסמוך לאחר התגלות עילת ההתנגדות.
5. כל צד ידאג להתייצבות עדיו לשיבת ההוכחות.
6. נקבע לשמיעת ראיות ביום 13.03.12 שעה 09:30.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים באמצעות הפקס.

ניתנה בלישכתי בתאריך י"ט כסלו תשע"ב, 15 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין